

1523046-70.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... de pena, considero a condenação por tráfico de drogas, imposta pela 14ª Vara Criminal (fls. 103/104 e 107/125), para não aplicar o redutor do tráfico privilegiado. Com efeito, a pregressa condenação, pelo mesmo delito, demonstra que o acusado está habituado a extrair seu sustento do tráfico ilícito de drogas, ou seja, é indivíduo que se dedica a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523046-70.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523046-70.2022.8.26.0228 PD 1274/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIKI DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17 de novembro de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, presente o réu Maiki dos Santos, acompanhado pela Dra. Laura Naves Filisbino - Defensora Pública. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência. Pela Defesa foi apresentada resposta à acusação nos seguintes termos: "M.M. Juiz, em atendimento ao artigo 396 do CPP, a Defesa apresenta resposta à acusação, pugnando pela absolvição do acusado. Outrossim, por estratégia, a Defesa consigna que apresentará os argumentos de mérito, após a instrução processual. Com relação à instrução probatória, arrola-se, em comum, o rol acusatório, ressaltando-se o direito a eventual acréscimo e/ou substituição, se necessário for." A seguir, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem

produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: “MM. Juiz, o réu MAIKI DOS SANTOS foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, porque, 10 de outubro de 2022, na Rua Cristóvão Pereira, nesse município e Comarca da Capital, trazia consigo/ guardava, para fins de tráfico, 12 porções contendo substância entorpecente denominada “Crack” w 15 porções de substância entorpecente denominada “Cocaína”, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 11, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, consoante laudo de constatação de fls. 18/21 e laudo de exame químico toxicológico que será oportunamente juntado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Após o recebimento da denúncia (fls. 57/59), o réu foi devidamente citado (fl.) e ofereceu defesa prévia. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 06/09, auto de exibição e apreensão de fls. 11, bem como pelo laudo de constatação de fls. 03/06 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls., que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, ao ser interrogado, o réu reservou-se ao direito de permanecer calado (fls. 05). Em juízo, negou a acusação. A negativa do réu restou isolada. Vejamos. Ouvida na fase inquisitiva os policiais LUCAS E FILIPE narraram a fls. 04/05 que realizavam diligência no local, quando avistaram um indivíduo debruçado em um veículo em local sabidamente de tráfico de drogas. Realizaram a abordagem e o indivíduo foi identificado como Maiki dos Santos, vulgo “Golf”, com uma bolsa marrom pequena contendo 15 porções de cocaína e 12 de crack, além do valor de R\$ 3.111,00, em notas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00. Indagado, afirmou que abastece com drogas a comunidade do “Zoião”, que estava aguardando um cliente que iria retirar a droga. O policial FELIPE em juízo ratificou a versão apresentada pelo seu companheiro de farda. Disse que visualizaram o réu debruçado num veículo em local conhecido pela comercialização de drogas. Com ele tinha uma bolsa marrom feminina o que despertou a suspeita. Resolveram abordá-lo. Nesta bolsa havia 15 porções de cocaína e 12 de crack. Havia ainda uma quantia em dinheiro, mais de R\$ 3.000,00, em notas de 20 e 10 reais. Ele confessou que abastecia uma favela com drogas. Ele falou que estava esperando um cliente para entregar a droga. Ali é uma comunidade chamada comunidade do piolho. Tem uma viela que as pessoas costumam entregar drogas para os carros que passam. Reconhece o réu. No mesmo sentido, o depoimento do policial LUCAS em juízo, que também reconheceu o réu pessoalmente e disse que o réu confessou que as drogas abasteceriam a comunidade do Zoião. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão, quantidade e variedade de drogas e a apreensão de dinheiro e notas trocadas, evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a

pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso... A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho... Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação se incumbiu de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes do autor foi recentemente condenado por crime da mesma natureza. Já na segunda fase, observo a sem agravantes nem atenuantes. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico ausente a causa de diminuição de pena, uma vez que o réu não ostenta bons antecedentes, tendo inclusive condenação recente pelo mesmo delito. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais¹. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da

mercancia de entorpecentes, conseguem ainda “lavar” o dinheiro obtido, depositando-o na conta de “laranjas” fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado,

que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado”. Não há dubiedades, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Ainda, o réu seja tecnicamente primário, verifico recente condenação por crime da mesma natureza. Portanto, em sendo considerado hediondo e pela reincidência do réu, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena.”

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: “MM. Juiz, MAIKI DOS SANTOS, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, órgão munido das prerrogativas de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os prazos processuais[1], apresentar alegações finais, da forma que segue. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos descritos na denúncia. O acusado foi notificado, citado, foi apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridos dois policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e o acusado foi interrogado ao final. Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. Em que pese a respeitável a manifestação ministerial, a ação penal é improcedente, como de passa a demonstrar. O policial militar PM Felipe Prado Tavares narrou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou um indivíduo debruçado em um veículo em local que é ponto de tráfico. Deliberaram pela abordagem. O indivíduo portava uma bolsa marrom feminina que levantou suspeita. Na bolsa marrom havia 15 porções de cocaína e 12 porções de crack além de R\$3100,00 em notas de R\$10 e de R\$20. Maiki disse que estava esperando um cliente para entregar droga. Disse ainda que fornecia drogas em outras comunidades. Foi encaminhado para o DP sem uso de algemas porque Maiki estava bem calmo. Foi a primeira vez que abordou o réu. O local é a comunidade do piolho. Tem uma viela por onde as pessoas saem para fazer entrega de droga para pessoas que passam, por isso suspeitaram que ele estava na venda. O policial militar LUCAS MASSOLA FERNANDES, em seguida, declarou em juízo que a equipe estava em patrulhamento quando viu indivíduo debruçado na janela de um veículo em local que já conhecia por tráfico de drogas. Realizaram a abordagem. Maiki estava com bolsa feminina transversal marrom. Maiki disse que estava desembarcando e efetuando pagamento do Uber. Perguntaram o que tinha dentro da bolsa primeiro não quis responder, mas depois disse que tinha dinheiro e porções de droga que tinha para fornecer para cliente. Ele mesmo disse que fazia função de “abastece” na comunidade de zoião. Na bolsa, continha dinheiro e entorpecente. O próprio réu disse que estava esperando o cliente para fornecer droga e um maço de cigarro. Foi a primeira vez que viu Maiki. Recordar-se do réu apresentado em audiência. A pessoa dentro do veículo era motorista de Uber, apresentou a corrida pelo aplicativo e foi liberado no local dos fatos. Em seu interrogatório, Maiki negou os fatos. No dia dos fatos, a mãe do réu o chamou para conversar na casa dela porque ele estava morando na rua

e usando de droga; é sua mãe afetiva; a mãe biológica morreu assassinada quando tinha 6 meses de vida. Sua mãe afetiva queria tirar o réu da rua. Onde morava, na comunidade do piolho, todos os barracos pegaram fogo. Como já usava droga, começou a morar na rua e experimentou o crack. A mãe deu R\$3.500,00 para construir um novo barraco e sair da rua. Quando viu o dinheiro, foi à comunidade ao lado, comprou droga, voltou para casa de sua mãe para se despedir e voltar para a comunidade estava dormindo. A mãe chamou um Uber para leva-lo porque já era de noite. A corrida deu R\$14,00, mas só tinha o dinheiro que a mãe deu, que estava em notas trocadas. Estava conversando com Uber na porta do carro e viu quando a polícia entrou na rua, mas não correu porque não estava envolvido. Falou para os policiais que tinha dinheiro e droga no bolso. Falou para eles que a mãe tinha dado dinheiro. O local onde foi abordado é ponto de tráfico. Os policiais acharam R\$3.100,00 pois já tinha gastado com drogas e cigarro. Policiais mostraram fotos de traficantes do local e pediram para indicar onde estariam, mas o réu disse que não conhecia nenhum deles. Foi até a viatura sem algema porque não ofereceu resistência. Estava na posse de drogas, com crack e cocaína. As drogas eram para seu consumo pessoal. Não ia vender as drogas. Ficava na calçada, em maloca, como uma mini Cracolândia. Assim, o conjunto probatório não indica certeza da autoria do delito: os policiais disseram que a droga foi apreendida com o réu que teria confessado traficância, mas o réu negou os fatos, dizendo que portava droga para consumo pessoal. Trata-se, portanto, de um caso no qual repousam sérias dúvidas acerca da configuração delitiva. Não há provas cabais de autoria delitiva, capazes de afastar a versão do acusado. De tudo quanto exposto, se depreende que, ao menos, resta dúvida fundada, que deve ser interpretada em favor do réu, por imposição do estado constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII). A incerteza não compactua com o juízo normativo exigido para a condenação. Pelo exposto, requer seja o acusado ABSOLVIDO, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Caso, diante de todas as provas contrárias, se entenda pela condenação requer sejam recebidos os seguintes pedidos. Requer seja a pena base fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06. Na segunda fase, requer-se a aplicação da atenuante da menoridade relativa, superando o entendimento da Súmula n. 231 do STJ em virtude do princípio da individualização da pena. Requer ainda a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo (2/3), tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. O fato de ter uma condenação anterior, contudo, sem trânsito em julgado, não obsta a aplicação do redutor, conforme entendimento do C. STJ: No que se refere à almejada incidência da minorante do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, a aplicabilidade da figura do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias ordinárias com base na existência de atos infracionais anteriores e pelo fato de o recorrente possuir ação penal em curso pela prática do mesmo delito (e-STJ fls. 281-282). Conforme salientado pelo ilustre membro do Parquet, não obstante os atos infracionais indicados guardarem relação com o tráfico, tratando-se de réu tecnicamente primário, sem registros de maus antecedentes e sendo pequena a quantidade de drogas apreendidas, entende-se ser cabível a reforma da dosimetria para aplicar a redutora relativa ao privilégio, em seu grau máximo, com base no princípio da proporcionalidade e por não restar caracterizada "circunstância excepcional", a autorizar a desconsideração da primariedade prevista para aplicação do benefício, visto que a quantidade de drogas envolvidas foi muito pequena (e-STJ fl. 542). Ademais, em que pese o fundamento empregado pelo Tribunal para inviabilizar a aplicação da causa especial de diminuição de pena, verifica-se que esta Corte de Justiça orienta que "A existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas." (AgRg no HC n. 694.354/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022). Na mesma direção: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 3 G DE COCAÍNA, 14,5 G DE COCAÍNA, 7 G DE COCAÍNA, 20 PINOS DE COCAÍNA E 5 PINOS DE

COCAÍNA.DOSIMETRIA.ALEGAÇÃO DE NÃO SER CABÍVEL A CAUSA DE DIMINUIÇÃO, EM FACE DE PROCEDIMENTOS INFRACIONAIS. DECISÃO MANTIDA. PRIMARIEDADE. RÉU SEM ANTECEDENTES. PENA-BASE NO PISO MÍNIMO. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. 1 A existência de procedimentos infracionais por tráfico de drogas e por ter sido abordado duas vezes no mesmo dia, sendo preso, após ser apontado em denúncias anônimas, não leva à conclusão de que o paciente se dedique a atividade criminosa, até porque a presente quantidade de drogas não é excessiva, o paciente é primário e sem antecedentes e a pena-base foi fixada no piso mínimo. 2 Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 671.690/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 27/9/2021.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.182/STJ. TRÁFICO. HABEAS CORPUS. PENA-BASE.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BENEFÍCIO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PROCESSO EM ANDAMENTO. PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.1 A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. 2 Quanto à exasperação da pena-base e à não aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo necessária a concessão de ofício de habeas corpus. 3. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 4 No presente caso, a quantidade do entorpecente apreendido (173, 45g de maconha) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento. 5 Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 6 Esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, em 21/9/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Precedentes. 7. Na hipótese em análise, constata-se que a ação penal utilizada pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação do recorrente a atividades criminosas encontra-se em andamento, sem trânsito em julgado, o que impede o uso dessa ação para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado. 8. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n.º 529.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). Precedentes. 9. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 2/3, em razão da quantidade da droga apreendida (173,45g de maconha), o que se mostra razoável e proporcional. 10 No que tange ao regime de cumprimento da pena, estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, sendo favoráveis as circunstâncias do art. 59 do CP, primário o recorrente e sem antecedentes, e considerada a quantidade total do entorpecente apreendido, o regime aberto é o adequado à prevenção e reparação do delito, sendo cabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

11 Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar o benefício do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando a pena do acusado GUSTAVO GOMES PIRES para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação, sem reflexo na pena final de MATHEUS DE ALMEIDA LIFONSO. (AgRg no AREsp n. 2.123.312/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.) Dessa forma, levando-se em conta a reduzida quantidade dos entorpecentes apreendidos (26,9g de maconha), e, ainda, a análise favorável das circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a aplicação da fração redutora em 2/3 (dois terços). (REsp 2016853. Relator Ministro Jorge Mussi. Data da publicação 17/11/2022). Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, "c" do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Deve-se ter por claro que o Pretório Excelso pacificou entendimento em seu Pleno de que é inconstitucional a previsão de obrigatoriedade de regime inicial fechado da Lei dos Crimes Hediondos (art. 1º, §1º), no HC 111.840/ES. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. Por fim, finda a instrução criminal e ausentes as hipóteses ensejadoras da constrição cautelar, requer o direito de apelar de eventual sentença condenatória em liberdade."

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. MAIKI DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado a fls. 50/52 como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de outubro de 2022, na Rua Cristóvão Pereira, nesta Capital, trazia consigo/guardava, para evidente fins de tráfico ilícito de drogas, 12 (doze) porções de crack e 15 (quinze) porções de cocaína, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, Laudo de Constatação de fls. 18/21 e L.E.Q.T. de fls. 94/96, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi preso em flagrante delito por Policiais Militares e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 57/59), o réu foi citado (fls. 105/106), sendo apresentada resposta à acusação. Durante a instrução criminal foram ouvidos os PMs responsáveis pela prisão em flagrante. O acusado foi ao final interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pediu a condenação e se opôs à aplicação do redutor correspondente ao tráfico privilegiado, em razão do acusado já contar com condenação por delito análogo, imposta pela 14ª Vara Criminal Central (cf. fls. 107/122). A Defesa, ao tecer suas considerações, pediu a absolvição.

Subsidiariamente pretendeu: a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; a fixação da pena no patamar mínimo; a aplicação da atenuante da menoridade relativa; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal; e o apelo em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Com efeito, autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram comprovadas: pelas circunstâncias da prisão em flagrante (A.P.F.D. de fls. 01 e seg.); pelos depoimento dos PMs (fls. 03/04); pelo teor do B.O. de fls. 06/09; pelo A.E.A. de fls. 11; pelo Laudo de Constatação de fls. 18/21; e pelos depoimentos dos PMs em Juízo. Ouvidos pela Autoridade Policial, por ocasião da lavratura do A.P.F.D., os PMs Lucas e Felipe asseveraram, de forma uníssona, que realizavam o patrulhamento ostensivo motorizado, a bordo da Viatura M12125, quando se depararam com o acusado MAIKI, debruçado junto a um veículo, em local sabidamente de tráfico de drogas. Realizaram então a abordagem do acusado que foi qualificado como MAIKI DOS SANTOS, o qual forneceu o vulgo de "GOLF". Com o réu havia uma bolsa marrom pequena em cujo interior encontraram 15 porções de cocaína e 12 porções de crack, além do valor de R\$ 3.111,00 (três mil, cento e onze reais) em notas de R\$ 20,00 e R\$ 10,00.

Questionado a respeito, MAIKI admitiu que fazia o tráfico de drogas, não propriamente na Comunidade do Piolho, mas sim abastecendo de entorpecentes a Comunidade do "Zoião". No momento da abordagem aguardava um cliente para o qual

entregaria a droga apreendida consigo. Ouvido em Juízo, o PM FELIPE reiterou os mesmos fatos, ou seja, durante patrulhamento de rotina juntamente com seu parceiro, avistaram o réu MAIKI debruçado em um veículo, sendo que o local já era conhecido por ser ponto de venda de drogas. Ao fazerem a abordagem, localizaram com o réu uma bolsa marrom, no interior da qual estavam as 15 porções de cocaína e mais 12 porções de crack, além de cerca de R\$ 3.100,00 em dinheiro, em notas de R\$ 10,00 e R\$ 20,00. Indagado a respeito, o réu confirmou que a droga se destinava à venda, sendo que aguardava pelo local um cliente, para o qual entregaria as substâncias. Indagado se o réu trabalhava no tráfico de drogas, o réu disse que não fazia o tráfico na Comunidade do Piolho, porém ele fornecia drogas em outras comunidades. O réu foi então conduzido ao DP onde foi lavrado o flagrante. Ouvido em Juízo o PM LUCAS, este confirmou idêntico contexto, ou seja, durante patrulhamento pelo local dos fatos, viram o réu MAIKI debruçado na janela de um veículo, em local que já era de conhecimento ser ponto de tráfico de drogas. Fizeram em seguida a abordagem do réu. O réu portava consigo uma bolsa marrom e no interior da mesma localizaram as porções de cocaína e crack, além de cerca de R\$ 3.100,00 em dinheiro. O próprio réu, de forma espontânea, disse que havia pego as drogas consigo apreendidas, para fornecer para um cliente, com o qual se encontraria pelo local. Portanto o acusado deixou claro que as drogas eram para o fim de tráfico, sendo que MAIKI ainda informou que sua função, na atividade do tráfico, era fazer o abastecimento de drogas na Comunidade do Zoião, situada nas imediações. Eis que o acusado, interrogado em Juízo, admitiu que realmente estava na posse das drogas consigo apreendidas. No entanto, alegou que as substâncias não seriam para tráfico, mas para seu uso pessoal. Disse ainda que o dinheiro lhe teria sido entregue pela mãe para construir um barraco para si. De todo o exposto, temos que restou isolada a alegação do acusado em Juízo, no sentido de que as 15 porções de cocaína e as 12 porções de crack, seriam meramente para consumo pessoal. Isto porque, tanto na fase policial, como em Juízo, os PMs foram categóricos em reiterar que o acusado prontamente admitiu que as drogas eram para fins de tráfico, tanto que aguardava pelo local um cliente, para quem entregaria os entorpecentes. Ainda, reafirmaram que MAIKI admitiu que era o “abastece” da Comunidade do Zoião. Outrossim, não se olvide que a variedade e diversidade das drogas, embaladas em porções individuais, prontas para a venda, em local onde é notório o tráfico, também não se coaduna com a alegação de que serviriam apenas para consumo pessoal do acusado. Ainda, conforme fls. 107/125, o acusado já havia sido preso e condenado por tráfico de drogas cometido em 01/06/2021, sendo que valeu-se da liberdade concedida pela 14ª Vara Criminal Central, para tornar a extrair o sustento do comércio ilícito de entorpecentes, vindo a ser preso novamente em 10/10/2022. Destarte, concluo que a prova documental, pericial e testemunhal corroboraram na íntegra a imputação de tráfico. As circunstâncias em que ocorreu a abordagem, aliadas à quantidade, qualidade e forma de embalagem das drogas, indicam sua destinação ao tráfico. Mister se faz a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Fixo inicialmente a sanção no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase de dosimetria, não existem agravantes, sendo que a atenuante da menoridade penal relativa, não tem o condão de diminuir a pena além do patamar mínimo já aplicado. Já na terceira fase de dosimetria de pena, considero a condenação por tráfico de drogas, imposta pela 14ª Vara Criminal (fls. 103/104 e 107/125), para não aplicar o redutor do tráfico privilegiado. Com efeito, a pregressa condenação, pelo mesmo delito, demonstra que o acusado está habituado a extrair seu sustento do tráfico ilícito de drogas, ou seja, é indivíduo que se dedica a atividades criminosas e tem ligação inclusive com o crime organizado, visto que fazia o abastecimento de drogas na Comunidade do Zoião. Por esses fundamentos e demais argumentos apresentados pelo Ministério Público, decido pela não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Torno como definitiva a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo. Isto posto, CONDENO o réu MAIKI DOS SANTOS, RG 39.324.940 e CPF 438.205.558-03, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33,

“caput”, da Lei nº. 11.343/06. Tratando-se de réu que tornou a cometer tráfico de drogas, logo depois de já ter sido anteriormente condenado por delito análogo, bem como, por ser o tráfico de drogas equiparado a crime hediondo, deverá o sentenciado iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado, observando-se o disposto na Lei nº 8.072/90. Como já dito, o réu demonstrou que aufere a própria subsistência da criminalidade (narcotráfico). Cometeu o presente tráfico de drogas logo após haver sido colocado em liberdade pelo Juízo da 14ª Vara Criminal Central. Logicamente que em liberdade, voltará a delinquir, em detrimento da Sociedade. Além de presentes os pressupostos para a continuidade da custódia (preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal), nota-se que o sentenciado permaneceu preso cautelarmente durante o curso do processo e não tem o direito de apelar em liberdade, visto que um dos efeitos da sentença condenatória é justamente ser o preso conservado na prisão (RHC 3.473-4, 5ª Turma, rel. Min. Jesus Costa Lima, j. 23.3.94, v.u. 4.4.94, p. 6691). De rigor acautelar o meio social e a própria credibilidade na Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. Recomende-se o réu na prisão. Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do valor apreendido com o réu, em favor da União, com reversão para a SENAD. A droga deve ser incinerada. Demais objetos devem ser encaminhados para destruição. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidades legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA